



**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC**

SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO/LEY 1437 DE 2011

El artículo 84 de la Ley 1437 de 2011, establece que el Silencio Administrativo Positivo se configura *“Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso. El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este Código”*.

SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO/SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL

En términos constitucionales se puede definir la figura del silencio administrativo como una herramienta que el legislador ha dispuesto para que el ciudadano pueda: i) hacer valer sus derechos ante la administración de justicia, en el caso del silencio administrativo negativo, por cuanto no puede quedar indefinidamente a la espera de una respuesta por parte del este estatal encargado de resolverla, hecho que hace necesario crear un mecanismo para que pueda acudir ante la misma administración recurriendo el acto ficto o ante la jurisdicción o, ii) ver satisfechos sus derechos ante la omisión de la administración, en el caso del silencio administrativo positivo, en la medida en que el mutismo de aquella concreta en su cabeza un derecho. Sobre las opciones que tiene el ciudadano cuando opera el silencio administrativo negativo ha dicho esta Corporación en forma reiterada: “..., el administrado puede optar por acudir a la jurisdicción o por esperar una respuesta efectiva de la Administración, sin que esta última opción, que es un desarrollo del derecho de petición, pueda acarrearle consecuencias adversas, como sería la de que a partir del momento previsto para la operancia del silencio administrativo se contabilice el término de prescripción o de caducidad de la respectiva acción”. De esta manera, si bien se podría considerar que en el marco del Estado Social de Derecho la administración está en la obligación de dar respuesta oportuna, clara, concreta y de fondo a las solicitudes presentadas por los ciudadanos, en donde la consagración de una ficción sobre la negativa o aceptación de las peticiones pueden ser percibida como contraria a los postulados de la función pública y el respeto por los derechos fundamentales, si se tienen en cuenta que uno de los fines del Estado es garantizar los derechos consagrados en la Constitución y facilitar la participación de todos en las decisiones que lo afectan, artículo 2 constitucional; la Sala no duda en afirmar que esas presunciones resultan un instrumento adecuado para garantizar, entre otros, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, vulnerados por la omisión de la administración al no responder oportunamente los requerimientos elevados por los ciudadanos. Ficción que en los términos de nuestro ordenamiento no exime a la administración de absolver la solicitud, porque el derecho de petición sólo se satisface cuando el Estado profiriere respuestas claras, precisas y de fondo¹.

¹ Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 52 (parcial) de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

Dependencia:	Dirección General
Número del Proceso:	1704-00-2016-187
Número y fecha del fallo:	RESOLUCIÓN No. 17317-00009 06 de abril de 2017
Asunto:	Fallo de Primera Instancia
Criterio de Selección:	Declarar la Responsabilidad Disciplinaria

RESOLUCIÓN No. 17317-00009 06 de abril de 2017

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

OBJETO DE LA DECISIÓN

Una vez concluida la investigación disciplinaria tramitada en el proceso administrativo disciplinario número 1704-00-2016-187, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo a lo que sigue.

IDENTIDAD DE LA INVESTIGADA

XXXXX XXXXX identificada con cédula de ciudadanía No. XXXXX de La Estrella (Antioquia), ostenta la calidad de servidora pública como quiera que se encuentra vinculada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN desde el 01 de julio de 2015, con un nombramiento de tipo provisional en el cargo de XXXXX XXXXX, con estudios técnicos en Asistencia Administrativa, y quien para la época de los hechos investigados se encontraba ubicada en el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín.

HECHOS

La presente actuación tiene su origen en la información suministrada por parte de XXXXX XXXXX, Jefe del GIT de Secretaría de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, quien mediante oficio No. XXXXX XXXXX del 24 de agosto de 2016 puso en conocimiento de XXXXX, Subdirector de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN, el Silencio Administrativo Positivo decretado dentro del Expediente DP 2016-2016-0000443, a través Resolución No. 1-90-201-236-408-3171 del 22 de agosto de 2016, al no haberse resuelto dentro de los términos legales establecidos en el artículo 515 del Estatuto Aduanero el recurso de reconsideración interpuesto por la representante legal de la sociedad XXXXX XXXXX. con NIT XXXXX, habida cuenta que no fue objeto de traslado a la División de Gestión Jurídica de la Seccional, por lo que transcurrió el tiempo sin que se hubiese tomado determinación de fondo por parte de la administración.

ACTUACION PROCESAL

La Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC, mediante Auto No. 17403-00136 del 14 de octubre de 2016, dispuso la apertura de la etapa de indagación preliminar en aras de verificar la ocurrencia de la irregularidad denunciada, determinar si constituía falta disciplinaria o si se había actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad e identificar y/o individualizar al funcionario que hubiese intervenido en los hechos materia de investigación.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

Con Auto No. 17412-00001 del 23 de febrero de 2017, el Despacho dispuso citar a audiencia a la señora XXXXX XXXXX, como funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para así continuar la presente actuación bajo los parámetros del procedimiento verbal; decisión de la cual se notificó personalmente la investigada el 2 de marzo de 2017.

El día 15 de marzo de 2017 se dio inicio a la audiencia de procedimiento verbal dentro del proceso adelantado bajo el radicado No. 1704-00-2016-187 y en desarrollo de la misma, el apoderado de la investigada solicitó pruebas, las cuales fueron decretadas por parte de este Despacho al considerarlas conducentes, pertinentes y necesarias para la presente investigación, por lo cual se procedió a suspender la audiencia para llevar a cabo la práctica de las mismas en la ciudad de Medellín. Así las cosas, para el día 05 de abril de la presente anualidad, se continuó con la audiencia iniciando con la ampliación de la versión libre de la investigada y se procedió con los alegatos de conclusión por parte del apoderado de la defensa.

5. CARGO FORMULADO

Por medio del Auto No. 17412-00001 del 23 de febrero de 2017, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la U.A.E. Agencia ITRC, formuló pliego de cargos a la investigada XXXXX XXXXX. El cargo disciplinario formulado resultó del siguiente tenor:

CARGO ÚNICO

"XXXXX XXXXX, en su calidad de funcionaria de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, presuntamente incurrió en la falta disciplinaria gravísima descrita en el numeral 35 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, toda vez que en desarrollo de sus funciones al interior del Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, al parecer, no corrió traslado a la División de Gestión Jurídica de la Seccional para que la misma resolviera el recurso de reconsideración interpuesto por la representante legal de la sociedad XXXXX XXXXX. con NIT XXXXX, radicado el día 3 de febrero de 2016 con el No. 1447, el cual le fue entregado mediante planilla de reparto el día 4 de febrero de 2016 para los fines pertinentes.

Lo anterior, tuvo como efecto que el recurso interpuesto el 3 de febrero de 2016 no hubiese sido resuelto dentro del término legal de tres meses (3) que para el efecto establece el artículo 515 del Estatuto Aduanero, por lo que la Administración debió declarar que el Silencio Administrativo Positivo había operado, tal y como lo reconociera a través de la Resolución No. 1-90-201-236-408-3171 del 22 de ^ agosto de 2016 dentro del Expediente DP 2016 2016 0000443, en aplicación del artículo 519 de la normativa en comento".

ARGUMENTOS DE DEFENSA:**VERSIÓN LIBRE, DESCARGOS Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

En ejercicio de su derecho de defensa, la señora XXXXX XXXXX rindió versión libre en la cual manifestó que desde su ingreso a la entidad, el 1° de julio de 2015 y para la fecha de los hechos investigados, se encontraba ubicada en el Grupo de Secretaría de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera, donde era la encargada de abrir los expedientes de situación jurídica, los cuales llegan de la División de Gestión de Operación Aduanera, del Grupo de Fiscalización y de la POLFA, adicional a los que llegan de Quibdó y Montería. Añadió que diariamente tramitaba un aproximado de 60 expedientes, frente a los cuales debía revisar los nombres, los NIT y verificar que la constancia de foliación indicada en la hoja de ruta estuviera correcta; asimismo, debía ingresar al sistema CORAN toda la información del acta de aprehensión y todos los oficios, aparte de ingresarle los documentos adicionales al expediente, y también ingresaba al sistema los DIAM, que es la información de la mercancía y el precio total de la misma. Luego de eso, entregaba los expedientes al jefe para que él los revisara y firmara los autos de apertura y la planilla,

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

para finalmente hacer el reparto a los funcionarios con una planilla de decomisos ordinarios y directos.

Del recurso de reconsideración radicado el día 3 de febrero de 2016 por la representante legal de la empresa XXXXX XXXXX, frente al cual operó el silencio administrativo positivo al no haberse resuelto dentro de los términos legales, manifestó que ella se enteró de la situación presentada cuando su jefe le dijo que no se había contestado el recurso, miraron las planillas y vieron que ella lo había recibido porque estaba su firma, pero no sabía cómo había llegado al expediente, pues al revisar la carpeta, el mismo no estaba foliado ni estaba relacionado en la hoja de ruta, y adicionalmente apareció en la parte de adelante del expediente, cuando debía estar en la parte de atrás.

Adicionalmente señaló que ella era muy cuidadosa con esos documentos porque sabía la importancia que tenían y considera que debieron traspapelarse, pues siempre que llegaba un recurso o una objeción, foliaba los documentos y dejaba la constancia en la hoja de ruta, resaltando que, al finalizar, los expedientes eran revisados por su jefe y por las funcionarias XXXXX XXXXX y XXXXX XXXXX, quienes verificaban al momento de archivarlo, que toda la foliación estuviera completa y que no hubiese ninguna anomalía con los nombres, las cédulas y los NIT. De igual forma, recordó que para esa época le ayudaba una practicante de nombre Diana, dada la cantidad de documentos que llegaban a la División, y no sabía si fue ella quien en ese momento vio el recurso y lo anexo al expediente.

En desarrollo de la audiencia de proceso verbal, la investigada allegó de forma escrita ampliación de su versión libre al cual dio lectura manifestando que, el procedimiento establecido en la entidad para el ingreso de documentación, es que la misma, una vez recibida en la oficina de Documentación Aduanera, el personal de dicha área era el encargado de seleccionar el tipo de documento y de enviarlo a la dependencia correspondiente.

De igual forma, señaló que la dependencia en la cual ella laboraba se denomina Fiscalización Aduanera, razón por la cual todas las actas de aprehensión de mercancía llegaban allí, y su función consistía en relacionar la documentación que llegaba en el sistema CORAN y asignarle un funcionario para el trámite del proceso; indicó que esa información quedaba relacionada en una planilla de reparto de situación jurídica, y a su vez, el mismo sistema arrojaba unos documentos que se imprimían para efectos de armar el correspondiente expediente. Luego de eso, dicho expediente se pasaba al jefe del grupo interno de trabajo, quien firmaba los autos pertinentes y la planilla de reparto, y después de estar firmados, su función era repartir el expediente al funcionario encargado de tramitarlo, según le indicara el jefe del GIT.

Asimismo, indicó que una vez conformado y asignado el expediente al funcionario que lo debiera tramitar, la documentación que llegaba a la DIAN con destino a tal expediente, de acuerdo con la selección que se hace en la oficina de Documentación, se le envía a la Secretaria de la oficina de Fiscalización y ella lo redireccionaba al funcionario encargado del proceso, esto es, a quien le fue asignado por el sistema CORAN, sin que dicho expediente regresara por ningún motivo a sus manos.

Respecto de los recursos de reconsideración manifestó que, según directrices de la DIAN y teniendo en cuenta la importancia de los mismos, desde la oficina de Documentación Aduanera se debía identificar que era un recurso de ese tipo y se debía enviar a la oficina Jurídica, sin pasar por la División de Fiscalización Aduanera, es decir, la oficina en la que ella trabajaba; resaltando que, en la misma acta de aprehensión dice que precede el recurso de reconsideración ante la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Medellín dentro de los 15 días siguientes a su notificación, de acuerdo con el Art. 512-1 del decreto 2685 de 1999, adicionado por el Art. 21 del decreto 4431 del 30 de diciembre del 2004, ya que la División de Fiscalización Aduanera no era la competente para resolver recursos de reconsideración.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

Así las cosas, en su consideración, el documento por el cual se inició la presente investigación, frente al cual no se dio respuesta a tiempo, nunca debió pasar por sus manos, pues el mismo debía llegar directamente a la Jurídica, independientemente de que el proceso hubiese sido asignado o no a un funcionario específico, resaltando que al llegar a su oficina ella no tenía por qué saber que se trataba de un recurso de reconsideración, más teniendo en cuenta que al leerlo en ninguna parte decía que se trataba de un recurso, y que en la planilla por medio de la cual se le hizo entrega del mismo tampoco decía eso, adicional a que ella no es abogada y que no tenía la función de examinar el contenido de los documentos que se le entregaban con el fin de resolverlos, pues su función simplemente era la de "efectuar el ingreso y salida de correspondencia del área, de acuerdo con las normas, procedimientos y directrices establecidas" así como de "ejecutar las labores de mensajería interna y externa que garantice la clasificación, el despacho y/o recibo de las comunicaciones, documentos, elementos y/o expedientes relacionados con los lineamientos y procedimientos establecidos" tal como consta en la certificación de funciones que obra al folio 11 del expediente.

Como prueba de lo anteriormente expuesto, aportó copia del documento por el cual se dice que se dio el silencio administrativo positivo, para que se observe que en el mismo no dice que sea un recurso de reconsideración.

Adicionalmente, considera importante señalar que sus funciones no eran desempeñadas solamente por ella, pues también se encontraba una practicante de la Universidad de Medellín con quien se distribuía la tarea de armar los expedientes y anexarles la documentación, por lo cual, si bien se evidenció que fue ella quien recibió el documento, es posible que el mismo haya sido manipulado por la practicante, pues no se manejaba ningún tipo de control sobre los documentos que organizaba cada una, más cuando siempre se trabajó en armonía y nunca hubo ningún problema con ello; y resaltó una vez más que, como quiera que los recursos de reconsideración nunca llegaban a su oficina, ni ella ni la practicante podían llegar a pensar que ese documento se tratara de un recurso, por lo que se trató como cualquier otra información que hubiera llegado.

Frente al Auto No. 6003 - 109 del 15 de septiembre de 2016, el cual señala que "la representante legal de Omega Store... interpuso recurso de reconsideración contra la mencionada acta de aprehensión; el mismo día se hace entrega del recurso a la funcionaria que lleva el proceso, es decir, a XXXXX XXXXX, documento que '(...) se debió incorporar al expediente en mención y hacer traslado a la División Jurídica para que se resolviera el recurso...", manifiesta la investigada que se equivoca porque ella no era la encargada de llevar esos procesos, solamente de armar el expediente para que luego se le entregara al funcionario que lo llevaba.

En consecuencia, considera que ella no tenía por qué estar involucrada en la presente investigación, por "dar lugar a la configuración del Silencio Administrativo Positivo al no dar traslado a la División de Gestión Jurídica para que se resolviera el recurso de reconsideración impetrado por la representante legal de la empresa XXXXX XXXXX respecto de la aprehensión realizada por la Policía Fiscal y Aduanera de Medellín mediante Acta No. 9000393 del 30 de enero de 2016", pues ese documento debió trasladarse a la División de Gestión Jurídica por parte del personal de la oficina de Documentación de la DIAN, es decir, que fue allí donde ocurrió el error y no en la dependencia donde ella laboraba.

Finalmente, la investigada aclaró que ella llevaba seis (6) en el cargo que se encontraba desempeñando para la fecha en que ocurrieron los hechos investigados; que ella recibió la debida inducción; que la practicante estuvo durante los 6 meses de práctica en el GIT de Secretaría; que el apoyo de la practicante consistía en que se repartían el trabajo a realizar, que ella no recibió ninguna instrucción acerca del traslado que debía realizar del documento en mención; y que la persona encargada de trasladar el documento.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

Alegatos de conclusión

En desarrollo de la audiencia del proceso verbal, el apoderado de la investigada presentó alegatos de conclusión centrando su argumento en qué, como primera medida el recurso de reconsideración que hoy es materia de investigación nunca debió llegar a manos de la señorita XXXXX XXXXX, como quiera que éste se radicaba en la oficina de Documentación Aduanera, donde se debía clasificar y se determinaba a donde debía dirigirse cada oficio que llegaba, y para el caso en concreto, el mismo debió dirigirse a la oficina Jurídica, pues era la competente para resolverlo, no la División de Fiscalización donde trabaja XXXXX XXXXX, es decir, que desde la oficina de Documentación no fue bien direccionado; resaltando que, como soporte del trámite que se le debía dar a los recursos de reconsideración que llegan a la entidad obran las declaraciones del jefe inmediato, de la secretaria, de la recepcionista, de la funcionaria del archivo y de la practicante, que en el momento de ser asignada a esa práctica esas directrices se la entregó la oficina de recursos humanos.

Adicional a que, en el mismo acto administrativo de aprehensión, se indicaba que ese recurso de reconsideración se tramitaba ante lo División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional, por lo que es claro que la persona que lo recibió lo direccionó mal.

De igual forma, indicó que cuando la documentación era dirigida a la oficina de Fiscalización Aduanera, primero era recibida por la secretaria, quien era la encargada de pasarla a la dependencia correspondiente para ser procesada, es decir, que antes de llegar a manos de la investigada XXXXX XXXXX, el documento pasaba por otras instancias encargadas de evaluar el contenido del mismo a efectos de determinar a donde debía dirigirse, si debía era para que XXXXX aperturara el expediente, o sí, como en este caso, se debía enviar a la oficina Jurídica por ser esa dependencia la que se resolvía los recursos de reconsideración.

De igual forma, señaló que dentro de las funciones asignadas a la investigada no se encontraba que ella tuviera que dar traslado a la oficina jurídica de ningún documento, pues a ella sólo le correspondía aperturar los expedientes con base en las actas de aprehensión que llegaran, ingresar la información al sistema CORAN e imprimir los autos que con base en esa información que se generaban, para luego hacer entrega del expediente al funcionario competente encargado de hacer el trámite correspondiente según la información obrante en el expediente, y entregado el mismo, ninguna otra actuación en relación con este le correspondía a la funcionaria XXXXX XXXXX.

Asimismo, indicó que en el manual de funciones de la investigada no se establecía que ella tuviera que leer, analizar y determinar qué era lo que decía ese documento, para establecer si debía enviarse o no a otra dependencia, haciendo especial énfasis en que del contenido del mismo no desprende que se tratara de un recurso de reconsideración, además, si la secretaria de la oficina de Fiscalización se lo había asignado, era porque debía tramitarse como cualquiera otro documento con los que debía abrirse el expediente, pues ella por su capacitación y el puesto que desempeña no tiene conocimientos jurídicos para analizar el fondo del mismo, por lo que ella simplemente le dio un trámite como un documento ordinario de los que llegaban a esa oficina, adicional a que este tipo de recursos nunca llegaban a la oficina de Fiscalización Aduanera.

De otra parte, resaltó que el documento se encontraba en turno para ser ingresado al sistema CORAN y aperturar el expediente correspondiente, y no puede afirmarse siquiera que fue XXXXX XXXXX quien lo manipuló, teniendo en cuenta que en la misma dependencia trabajaba en labores de apoyo una practicante en razón al cúmulo de trabajo que allí había, y ésta indiscriminadamente hacía las mismas funciones de la investigada, como ella misma lo manifestó en su testimonio.

Por lo expuesto, considera el apoderado de la investigada que de esta manera queda claro que XXXXX XXXXX no incumplió alguna obligación o deber de los contenidos en el Manual

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

de Funciones o en la Ley 734 de 2002, pues quedo como demostrado, el documento nunca debió enviarse a la oficina de Fiscalización sino a la oficina Jurídica, por lo tanto, quienes incumplieron con el deber de cuidado y a la postre dieron lugar a la configuración del silencio administrativo positivo fueron las personas que lo recepcionaron en primera instancia, esto es, las encargadas de la oficina de Documentación donde se radicó, o en su defecto, la secretaria de la oficina de Fiscalización, quien al recibirlo se lo asigno a la investigada como un documento regular para surtir el tramite ya descrito, en lugar de haberlo remitido a la oficina Jurídica.

De igual forma, considera que en el presente asunto surge la duda razonable que este documento hubiese sido tramitado por XXXXX XXXXX o también por la practicante, pues no existe hasta este momento certeza de lo ocurrido. Entonces, al no haberse infringido ningún deber o incumplido alguna obligación, no puede calificarse como falta disciplinaria, y la misma no fue antijurídica pues no afecto el deber funcional, por lo que las diligencias deben archivarse al tenor de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 734, como quiera que la investigada no cometió la falta endilgada, y para ello hace referencia a la sentencia del 23 de septiembre de 2015 con ponencia del Magistrado Jorge Octavio Ramírez, que habla de que el reproche que se le haga a la funcionaria investigada debe ser claro, preciso y concreto, lo cual no ocurre en el presente asunto.

CONSIDERACIONES DE INSTANCIA:**RAZONES DE LA DECISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN QUE SE BASA****MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA:**

Este Despacho es competente para proferir el fallo de primera instancia dentro de la presente investigación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con las previsiones del Decreto 4173 del 3 de noviembre de 2011.

En atención a lo ordenado en el Artículo 142 de la Ley 734 de 2002, no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, cuya apreciación debe corresponder a las reglas de la sana crítica, según lo establece el Artículo 141 ibídem.

De igual manera, deben reunirse de manera conjunta los requisitos de legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, reglados en los artículos 4, 5 y 13 de la Ley 734 de 2002, los cuales es menester se encuentren debidamente acreditados dentro del sumario a partir de elementos de prueba legalmente allegados al proceso.

DEL CASO EN CONCRETO

El artículo 129 de la Ley 734 de 2002 dispone que, el funcionario buscará la verdad real y para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad.

En igual sentido, el Código Disciplinario Único establece que las pruebas deberán apreciarse en conjunto, de conformidad con las reglas de la sana crítica y que no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.

Así las cosas, dentro del plenario obran como pruebas las cuales acreditan la materialidad de la falta disciplinaria y la responsabilidad en cabeza del funcionario investigado, las que se exponen a continuación:

Documentales

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

1. A folio 10 obra oficio de fecha 24 de octubre de 2016 suscrito por la Doctora XXXXX XXXXX, Subdirectora de Gestión de Personal de la DIAN, por medio del cual remitió certificación laboral de la funcionaria XXXXX XXXXX identificada con cédula de ciudadanía No. XXXXX, quien está vinculada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN desde el 01 de julio de 2015, con nombramiento de tipo provisional en el cargo de Facilitador I Código 101 Grado 01, y para la época de los hechos se encontraba ubicada en la División de Gestión de Fiscalización Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín. De igual forma, remitió las funciones delegadas a la funcionaria.

2. A folio 16 obra oficio de fecha 4 de noviembre de 2016 por medio del cual la Doctora XXXXX XXXXX, de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, remitió copia de la Resolución No. 1-90-201-236-408-3171 de fecha 22 de agosto de 2016 a través de la cual se decretó el Silencio Administrativo Positivo respecto del recurso de reconsideración interpuesto el día 3 de febrero de 2016, radicado con el número 1447, por la representante legal de la sociedad XXXXX XXXXX. dentro del Expediente DP 2016 2016 443.

3. A folio 46 obra Inspección Administrativa realizada el día 16 de noviembre de 2016 en la División de Gestión de Fiscalización Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, al Expediente DP 2016 2016 0000443 correspondiente al usuario XXXXX con NIT XXXXX, donde se logró establecer que el día 3 de febrero de 2016 la señora XXXXX XXXXX, representante legal de la empresa mencionada, presentó recurso de reconsideración en contra de la aprehensión realizada por la Policía Fiscal y Aduanera de Medellín el 30 de enero de 2016 mediante Acta No. 9000393; que el mismo fue remitido al GIT de Secretaría de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera el día 4 de febrero de 2016 y entregado a la funcionaria investigada a través de la Planilla denominada "Folio 22".

De igual forma que, el día 19 de julio de 2016 la representante legal de la empresa en mención radicó oficio solicitando la devolución del valor de la mercancía dado que los términos habían prescrito y no les habían notificado la respuesta del recurso presentado el 3 de febrero de 2016; y que el mismo fue remitido a través de la Planilla Múltiple de Remisión No. 599 a la División de Jurídica el 22 de julio de 2016.

En la diligencia de inspección también se incorporó como prueba a solitud de la funcionaria investigada, la planilla identificada como Folio No. 45 del 8 de febrero de 2016, por medio de la cual se entregó el expediente al archivo luego de su apertura, la cual se encontraba firmada por el jefe del GIT de Secretaría y la funcionaria encargada del archivo de expedientes, quienes debían revisar que la carpeta estuviera constituida y foliada en la debida forma; de otra parte, a solicitud de la funcionaria vinculada se hizo la revisión de un expediente diferente al objeto de investigación, a fin de verificar como se realizaba el proceso normal de apertura de expediente, desde que llegaba a sus manos hasta que se entregaba al archivo de expedientes, aportándose prueba del mismo.

4. A folio 118 obran certificados de los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales de la señora XXXXX XXXXX identificada con C.C. XXXXX, consultados a través de las páginas web de la Procuraduría General de la Nación "www.procuraduria.gov.co", la Contraloría General de la República "www.controloria.gov.co" y la Policía Nacional de Colombia "www.policia.gov.co" prueba con la cual se logró establecer que, para la fecha de su expedición la funcionaria investigada no registraba sanciones ni inhabilidades vigentes.

5. A folio 129 obra oficio de fecha 16 de marzo de 2017 por medio del cual el señor XXXXX XXXXX, jefe de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera (A) de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, remitió certificación de la carga laboral diaria que la funcionaria investigada XXXXX XXXXX tenía para los meses de enero, febrero y marzo de 2016, la cual se emitió con base en la información consultada en la base datos del aplicativo de control de radicaciones y notificaciones - CORAN, donde se reporta la cantidad de apertura y conformación diaria de expedientes.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

Pruebas testimoniales:

1. A folio 33 obra declaración rendida bajo la gravedad del juramento por la XXXXX XXXXX, quien manifestó que entre los meses de enero y abril del año 2016 se desempeñó como secretaria en el GIT de Secretaría de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, donde sus funciones consistían atender al usuario interno y externo, recibir la correspondencia y entregarla al funcionario que llevara el expediente, previa verificación en el sistema y revisión del jefe, lo cual hacía a través de una planilla que se firmaba con la fecha de entrega. De igual forma, indicó que asesoraba a los usuarios que se acercaban a preguntar sobre las aprehensiones, atendía las llamadas telefónicas, hacía los trámites para solicitar transportes, ubicaciones, pedir cerrajero para las resoluciones de registro, entre otras.

Sobre los recursos de reconsideración que ingresaban a la División, la testigo manifestó que los usuarios los radicaban en el GIT de Documentación y al día siguiente ellos se los entregaban a ella, luego de eso, ella revisaba si eran de decomiso ordinario o directo, si era un recurso o una objeción, y previa verificación en el sistema del lugar donde se encontraba el expediente, entregaba el documento, aclarando que si aparecía en Jurídica hacía el traslado correspondiente, pero si aparecía en funcionarios era porque lo tenía la persona encargada de abrir los expedientes, y en ese caso se lo entrega a esa persona por medio de la planilla de correspondencia, al cual le era asignado un número consecutivo y se le ponía la fecha.

Respecto del recurso de reconsideración impetrado por la representante legal de la empresa XXXXX XXXXX, manifestó que ella tuvo conocimiento de la situación presentada cuando se hizo la trazabilidad de lo que había ocurrido, y señaló que al ingresar el documento, ella miró la planilla donde estaba el número de aprehensión, buscó a quien correspondía y se lo entregó a XXXXX, previa revisión del jefe, quien él firmaba el documento que ingresaba antes de entregárselo al funcionario correspondiente, pero no recordó si para ese momento lo revisó el jefe de la División u otro jefe asignado.

Finalmente, señaló que el GIT de Secretaría no llevaba ningún control sobre los recursos de reconsideración que ingresan a la División de Gestión de Fiscalización.

En ampliación de testimonio rendido el día 16 de marzo de 2017, la señora XXXXX XXXXX manifestó que ha pasado por diferentes puestos de trabajo dentro del GIT de Secretaría en razón de las necesidades que se van presentando al interior de dicho grupo, que siempre ha recibido la inducción y capacitación necesaria para el desempeño de sus funciones, pero que de igual forma se presentan errores por la falta de práctica y la inexperiencia en el cargo.

Frente al direccionamiento de la documentación que llegaba al mencionado grupo de trabajo, señaló que ella siempre preguntaba ante cualquier duda y que, de igual forma, su jefe siempre revisaba la correspondencia antes de repartirla; y sobre las plantillas de entrega de documentos, señaló que el GIT de Documentación era quien las enviaba ya diligenciadas pero que ella las complementaba para que el funcionario que la recibiera entendiera lo que se le estaba entregando.

Sobre lo ocurrido con la funcionaria investigada XXXXX XXXXX manifestó que, no sabía cuál era su carga laboral, pero que sí era mucha, siempre le veía mucha documentación y esa era la razón por la cual ella tenía una practicante de apoyo, y las dos manipulaban los documentos que ingresaban, pero ella no le entregaba documentos a la practicante porque ésta no podía firmar; y que no sabía si fue a ella o a la practicante, a quien se le traspapelaron los documentos, porque eso lo manejaban las dos.

2. A folio 37 obra declaración rendida bajo la gravedad del juramento por el señor XXXXX XXXXX, quien manifestó que para el mes de febrero de 2016 se desempeñaba como jefe

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

del GIT de Secretaría de División de Gestión de Fiscalización Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín.

Respecto del trámite que se adelantaba al interior de la División sobre los recursos de reconsideración que eran radicados por parte de los usuarios aduaneros manifestó que, generalmente le llegan a la secretaria con un radicado, ella los incluía en el sistema para repartirlos por medio de una planilla, luego los revisaba el Jefe de la División o en su ausencia él como jefe de la Secretaría, y si eran de fácil clasificación, la misma secretaria lo asignaba al funcionario y él lo revisaba; luego ella imprimía la planilla y si el expediente estaba abierto se enviaba junto con el recurso a la División de Gestión Jurídica, pero si no estaba abierto se le entregaba a la persona que lo iba a abrir para que se le diera traslado a Jurídica dentro de los 5 días siguientes, puesto que ellos eran los responsables de definir la situación del recurso.

Sobre el recurso de reconsideración impetrado por la empresa XXXXX XXXXX, el cual es objeto de la presente causa disciplinaria manifestó que, se enteró de dicha situación en el mes de agosto cuándo el usuario se presentó en la oficina para preguntar sobre la respuesta del mismo, por lo que de inmediato se procedió a hacer la trazabilidad de lo que había pasado y vieron la planilla que había hecho la secretaria, que para el caso fue la funcionaria XXXXX, donde se evidenció que ella se lo entregó a XXXXX y ya con la planilla revisaron el expediente físico donde se percataron que ya estaba archivado y que dentro de la carpeta estaba el escrito de objeción, pero el mismo no estaba relacionado en el expediente y tampoco estaba foliado. Luego de eso, realizaron el traslado a la División de Gestión Jurídica para que se pronunciaran al respecto.

De igual forma, adujo que en aras de establecer qué era lo que había ocurrido se habló con las funcionarias XXXXX, con XXXXX XXXXX, que era la encargada del archivo de los expedientes, y con la secretaria XXXXX, pero no se encontró una explicación al respecto, resaltando que la funcionaria XXXXX XXXXX indicó que, al momento de recibir el expediente el recurso no se encontraba dentro del mismo, pues ella había realizado la verificación al revisar la hoja de ruta; asimismo señaló que, para ese momento los recursos de reconsideración eran entregados a la persona que abría el expediente y se le decía a la persona encargada de los traslados que lo hiciera de inmediato; y advirtió que, para esa época había una practicante en el GIT de Secretaría que le colaboraba a XXXXX con la organización de los documentos y las carpetas.

De las funciones asignadas a la funcionaria XXXXX XXXXX dentro del GIT de Secretaría señaló que, estas consistían en aperturar los expedientes de situación jurídica, organizarlos y repartirlos de acuerdo al proceso, ordinarios para los auditores y los de decomiso directo para el archivo de expedientes, y también debía alimentar las bases de datos, ingresar los datos del expediente en el CORAN y la información de documentos adicionales pertenecientes al mismo expediente; así mismo señaló, que la funcionaria recibió la debida capacitación por la persona a quien ella reemplazó, esto es, la funcionaria XXXXX XXXXX.

Finalmente, manifestó que XXXXX XXXXX era la encargada de entregar los expedientes a la XXXXX XXXXX, encargada del archivo, pero qué en ausencia de esta última, cualquier funcionario podía ingresar al archivo y revisar los expedientes.

En ampliación de testimonio rendido el día 16 de marzo de 2017, el señor XXXXX respecto de los hechos que nos competen manifestó que, sobre las funciones desempeñadas por la funcionaria XXXXX XXXXX se ejercía un control de calidad a través de unos formatos manejados por la entidad, pero que éstos no se hacían sobre el cien por ciento, sino que eran aleatorios y desafortunadamente ese control no se tuvo en cuenta para la fecha en que ocurrieron los hechos que aquí se investigan; pero que el desempeño laboral de la funcionaria investigada era muy bueno, que el cumplimiento de sus labores era excelente y que la misma no había incurrido en abuso de derechos o en extralimitación de sus funciones.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

Sobre la carga de trabajo de la investigada, manifestó que la misma era elevada, que a veces tocaba colaborar y esa era la razón por la cual para esa época tenía una practicante que le ayudaba, pero ésta no era una persona experta pues tenía muy poco conocimiento sobre el proceso; asimismo indicó que, esta persona que llegaba a la DIAN mediante convenio para realizar su práctica y la escogía la oficina interna de personal; y que él personalmente no estaba de acuerdo con que se pusiera una persona que no era idónea en ese cargo, pero en sus palabras, eso era lo había.

De igual forma, señaló que los practicantes hacían la misma labor de la investigada XXXXX XXXXX después de estar capacitados, pero cuando llegaba se hacía la aclaración que ésta era un apoyo y que el funcionario era quien respondía.

De otra parte, indicó que había dos tipos de escritos que el usuario podía presentar, uno era el escrito de objeción que lo tramitaba Fiscalización, y el otro, era el recurso de reconsideración que lo tramitaba Jurídica, aclarando que el escrito llegaba a documentación y si era un recurso de reconsideración se debía tramitar por Jurídica. Adicionalmente indica que, en el caso en que no se tiene claridad sobre si el documento recibido en un recurso de reconsideración o un escrito de objeción, este debe ser entregado a la persona a la cual le fue asignado el expediente, motivo por el cual el documento se le debió entregar a Juliana; sobre el momento en el cual se pudo haber desencadenado el hecho que diario lugar posteriormente al acaecimiento del silencio administrativo positivo, el declarante indica que, cuando se percataron que no se había dado tramitado el recurso, pero que si había sido recibido, se revisó la planilla, en la cual se evidencio que había sido recibido por Juliana, toda vez que ella firmaba la planilla, sobre la manipulación del documento indica que por experiencia sabe que en ocasiones otras personas involuntariamente cogen los paquetes que se tienen ahí, y resalta que al puesto de la investigada van funcionarios de la POLFA, de entes aprehensores, de operación aduanera y los mismos funcionarios de fiscalización, sobre la responsabilidad de los practicantes que se encuentran asignados a las diferentes áreas el declarante señaló que estos se encuentran libres de cualquier responsabilidad, toda vez que en los manuales de funciones simplemente no existe la figura de practicantes, motivo por el cual indica no saber quién responde por el trabajo de los practicantes.

3. A folio 145 obra declaración rendida bajo la gravedad del juramento por la señora XXXXX XXXXX, quien manifestó que conocía a la funcionaria investigada porque trabajo con ella en las prácticas de su carrera de negocios internacionales, las cuales adelantó en la División de Fiscalización Aduanera de la DIAN para el mes de febrero de 2016, donde le ayudó a XXXXX XXXXX y a otros compañeros a hacer su trabajo.

Señaló que, sus funciones con respecto a la ayuda prestada a XXXXX XXXXX consistían en organizar los expedientes, poner la carátula, organizar los documentos y foliarlos, ingresarlos al sistema y empapelarlos; y que para la realización de dichas tareas recibió capacitación por parte de XXXXX XXXXX, dijo que al comienzo ella se tomó un tiempo para explicarle y luego, en el momento en que ella lo necesitara le explicaba.

Manifestó que no recordaba como se debía adelantar el trámite de los recursos de reconsideración al interior de la División, como tampoco recordaba el recurso objeto de la presente investigación, ni la razón por la cual no se le dio respuesta al mismo, pero señaló que la carga de trabajo que tenía XXXXX XXXXX era demasiada, que tenía muchos expedientes y documentos para organizar, y que el manejo de esos documentos no era exclusivo de ella porque otros funcionarios también podían manipularlos.

4. A folio 149 obra declaración rendida bajo la gravedad del juramento por la señora XXXXX XXXXX, funcionaria de la DIAN, quien manifestó que para el mes de febrero de 2016 se encontraba ubicada en el grupo de Secretaría de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, y que su función consistían en recibir los expedientes que quedaban en el archivo para luego darles

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

traslado al archivo central, y algunos eran solicitados por la División Jurídica cuando se presentaban recursos; en razón de ello conocía a la funcionaria investigada XXXXX XXXXX.

Frente al trámite que debía adelantarse al interior de la División una vez se radicaban los recursos de reconsideración por parte de los contribuyente señaló que, el Grupo Interno de Documentación recibía todos los documentos que eran radicados por los usuarios y ellos eran los encargados de hacer llegar a las diferentes áreas o Divisiones según correspondiera, para el caso de la División de Fiscalización, la secretaria era quien recibía los radicados que correspondían a esta División y los hacía llegar al funcionario que tuviera a cargo el expediente, y en caso de que el escrito no correspondiera a esa División, con la misma planilla se devolvía al área que corresponda o a la administración.

Respecto del recurso de reconsideración objeto de la presente investigación señaló que, nunca vio el documento, que ella se dio cuenta de la situación presentada sino hasta tiempo después, y que no se le dio respuesta al mismo porque la División de Fiscalización no era la competente para resolverlo.

De igual forma, señaló que al interior de la entidad se podía presentar un mal direccionamiento de los documentos que son presentados por los usuarios o que venían de otras administraciones, debido a la falta de experiencia de los funcionarios en el puesto de trabajo o por la cantidad de documentos que se reciben en un solo día, y los controles para manejar este tipo de situaciones podían ser ineficaces; asimismo, indicó que la entidad no cuenta con suficiente personal para tanta carga de trabajo que existe en las distintas Divisiones, específicamente en el grupo interno de Secretaria, y es por ello que se recurre a pasantes y practicantes de las distintas universidades del área metropolitana, los cuales no cuentan con la suficiente experiencia para ejercer estas actividades tan delicadas y adicional sólo están seis meses y deben rotar en los distintos cargos que se tiene en Secretaria, en Cambios y en Investigaciones Aduaneras, aclarando que los pasantes no firman ninguna planilla de recibo de documentos aunque efectivamente los reciban físicamente, pues ésta es una instrucción dada por la entidad y por lo tanto, el funcionario es quien asume todas las responsabilidades por las equivocaciones que puedan tener los pasantes.

Finalmente, indicó que en su consideración el origen de este silencio administrativo radicó en el mal direccionamiento del documento, lo cual no era responsabilidad de XXXXX XXXXX, adicional a que la responsabilidad de responder los recursos no era del área de Fiscalización sino de Jurídica; y respecto de la funcionaria XXXXX XXXXX manifestó que, en el puesto en que ella se desempeña la carga de trabajo es demasiada ya que se aperturan más de mil expedientes de situación jurídica por mes, pero a pesar de eso, ella desempeña su puesto de trabajo con gran celeridad y responsabilidad.

VALORACIÓN EN CONJUNTO DE LAS PRUEBAS

Es necesario resaltar que la finalidad del proceso disciplinario es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen. Igualmente, que la decisión que toma el operador disciplinario debe fundamentarse en las pruebas legal y válidamente incorporadas al proceso, las cuales han sido objeto de análisis para la motivación de la decisión disciplinaria. Por esta razón, se hace necesario valorar en conjunto las pruebas referidas en el caso particular.

Como primera medida, de acuerdo al acervo probatorio obrante en el expediente se encuentra probado que la señora XXXXX XXXXX efectivamente ostenta la calidad de servidora pública como quiera que es funcionaria activa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN desde el 01 de julio de 2015, que su nombramiento es de tipo provisional en el cargo de Facilitador I Código 101 Grado 01 y que para la época de los

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

hechos se encontraba ubicada en la División de Gestión de Fiscalización Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín.

Adicional a la condición de servidora pública, se logró establecer que dentro de las funciones asignadas para el momento en que ocurrieron los hechos objeto de la presente investigación, se encontraba la de ejecutar las labores de mensajería interna en aras de garantizar el despacho de las comunicaciones, documentos, elementos y expedientes relacionados con los procesos que se desarrollaran en la dependencia, conforme a los lineamientos establecidos.

En el mismo sentido, el XXXXX XXXXX, Jefe de GIT de Secretaría de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera de la Seccional, en diligencia de testimonio señaló que en términos generales la función de la investigada XXXXX XXXXX dentro de dicha dependencia consistía en abrir los expedientes de situación jurídica, organizarlos y repartirlos de acuerdo al proceso, los procesos ordinarios los entregaba a los auditores y los proceso de decomiso directo los llevaba al archivo de expedientes; también tenía la función de alimentar las bases de datos, ingresar los datos del expediente en el CORAN y la información de documentos adicionales pertenecientes al mismo expediente.

También se encuentra probado que, el día 3 de febrero de 2016 la señora María Luz Santamaría Toro, representante legal de la empresa XXXXX XXXXX, presentó recurso de reconsideración en contra de la aprehensión realizada por la Policía Fiscal y Aduanera de Medellín el día 30 de enero de 2016 mediante Acta No. 9000393, ante el GIT de Documentación de la Seccional, el cual fue radicado con el número 1447; que al día siguiente, es decir, el día 4 de febrero de 2016, dicha documentación fue enviada al GIT de Secretaría de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera, donde le fue entregado a la investigada XXXXX XXXXX mediante la Planilla denominada "Folio 22", la cual fue firmada por ella misma como se logró constar a folio 83 del expediente disciplinario.

Asimismo, que el día 19 de julio de 2016 la representante legal de la empresa en mención radicó oficio solicitando la devolución del valor de la mercancía dado que a la fecha no se le había notificado la respuesta del recurso presentado el día 3 de febrero de 2016; y que el mismo fue remitido a través de la Planilla Múltiple de Remisión No. 599 a la División de Jurídica el 22 de julio de 2016 para lo fines pertinentes.

Al respecto, la funcionaria XXXXX XXXXX, secretaria del mencionado grupo de trabajo, señaló que al revisar la planilla que contenía el número de aprehensión, buscó a quien correspondía y se lo entregó a XXXXX, previa revisión del jefe, quien firmaba el documento que ingresaba antes de entregárselo al funcionario correspondiente, pero no tenía conocimiento de la razón por la cual no se le había dado respuesta al recurso de reconsideración impetrado por la representante legal de la empresa XXXXX XXXXX, pues ella se enteró de la situación presentada cuando revisaron toda la trazabilidad de lo que había pasado.

Por su parte, el Jefe de GIT de Secretaría de la División de Gestión Aduanera, señor XXXXX XXXXX, sobre el particular manifestó que tuvo conocimiento de la situación presentada con el recurso de reconsideración interpuesto cuando el usuario llegó a la oficina a preguntar por qué no se le había dado respuesta, ante lo cual hicieron la trazabilidad de lo que había pasado, miraron la planilla que había hecho la secretaria y vieron que ella se lo había entregado a la funcionaria investigada XXXXX XXXXX, y ya con la planilla verificaron el expediente físico donde evidenciaron que el mismo estaba archivado y dentro de él se encontraba el escrito de objeción, pero no estaba relacionado en el expediente y tampoco estaba foliado; y acto seguido hicieron el correspondiente traslado a la División de Gestión Jurídica para que se pronunciaran al respecto.

De igual forma, señaló que él habló con la funcionaria investigada XXXXX XXXXX, con la funcionaria XXXXX XXXXX, quien era la encargada de los expedientes, y con la secretaria del grupo de trabajo, la señora XXXXX XXXXX, pero no se logró saber qué era lo que

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

había pasado con el documento, pues el mismo no se encontraba dentro del expediente al momento de archivarlo.

Asimismo, el señor XXXXX XXXXX, al indicar cuál era el control que se llevaba al interior del GIT de Secretaría sobre los recursos, manifestó que tales documentos se entregan a la persona que abría el expediente y se le decía a la persona encargada de los traslados que lo hiciera inmediatamente, resaltando tales controles se realizaban de manera aleatoria y por ello no se percataron del recurso al cual no se le dio trámite; y también, que para la época en que ocurrieron los hechos objeto de la presente causa, había una practicante en el grupo de trabajo que les colaboraba con la organización de los documentos y ella le ayudaba a la investigada XXXXX XXXXX armando las carpetas con todos los documentos, pero que al llegar la misma al puesto de trabajo, se hacía la claridad que la responsabilidad recaía sobre la funcionario y no sobre el practicante.

De otra parte, el testimonio de XXXXX XXXXX, quien se desempeñó como practicante en la División de Fiscalización Aduanera para la época en que ocurrieron los hechos, no aporta elementos de juicio que permitan dar claridad a la situación, por cuanto adujo que no recordaba cómo se debía adelantar el trámite de los recursos de reconsideración al interior de la División, tampoco recordaba el recurso objeto de la presente investigación, ni la razón por la cual no se le dio respuesta al mismo, aunque efectuó indicaciones sobre los excesos en la carga laboral y en la descripción de sus actividades, sin que de ello se derive elemento alguno que demerite la acusación, amén que era la investigada quien por su condición funcional tenía en cabeza la actividad, ya que la practicante actuaba esencialmente como un apoyo a su gestión.

Frente a los hechos materia de la presente investigación, la señora XXXXX XXXXX, funcionaria de la DIAN quien se encargaba del archivo de los expedientes en la División de Gestión de Fiscalización Aduanera para ese momento, manifestó que nunca vio el documento, ya que ella se dio cuenta de la situación presentada sino hasta tiempo después, por lo que no es posible advertir elemento alguno que permita inferir un conocimiento preciso sobre la situación objeto de investigación; no obstante a partir de su testimonio si es posible plantear la dinámica en la que se ejecutaban las actividades del área, habida cuenta que refirió que el Grupo de Documentación recibía todos los documentos que eran radicados y ellos eran los encargados de hacer llegar a las diferentes áreas o Divisiones que correspondiera, y para el caso de la División de Fiscalización, la secretaria era quien recibía los radicados que correspondían a esta División y ésta los hacía llegar al funcionario que tuviera a cargo el expediente, y en caso de que el escrito no correspondiera a esa División, con la misma planilla se devolvía al área que corresponda o a la administración; todo ello, no obstante las falencias que se podían presentar en la ejecución del proceso a ellos asignado.

De otra parte, a solicitud de la investigada se incorporó como prueba la planilla identificada como "Folio No. 45" del 8 de febrero de 2016, por medio de la cual se logró establecer que al momento de enviarse el expediente al archivo, el mismo fue revisado por el jefe del GIT de Secretaría y por la funcionaria encargada del archivo de expedientes, quienes verificaron que la carpeta estaba constituida y foliada en la debida forma, y también se logró establecer, a solicitud de la investigada, cuál era el proceso normal de apertura de expediente, desde que llegaba a sus manos hasta que se entregaba al archivo de expedientes; y en etapa de descargos se allegó la relación de la carga que la misma tenía para la época de los hechos, la cual da cuenta de los expediente que aperturaba en desarrollo de sus funciones. Ello permite al Despacho advertir que el expediente fue enviado al archivo sin el documento recibido por la investigada, conforme a lo registrado en el formato de planilla 1447, por ella suscrito.

Finalmente, se encuentra probado que la División de Gestión Jurídica mediante Resolución No. 1-90-201-236-408-3171 del 22 de agosto de 2016, decretó el Silencio Administrativo Positivo respecto del recurso de reconsideración interpuesto el día 3 de febrero de 2016, radicado con el número 1447, por la representante legal de la sociedad XXXXX XXXXX.,

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

dentro del Expediente DP 2016 2016 443, al no haberse dado respuesta dentro de los términos de ley.

Recapitulando, el Despacho considera que existe certeza respecto al hecho de que la funcionaria investigada recibió el día 4 de febrero de 2016, el recurso de reconsideración interpuesto por la representante legal de la empresa XXXXX XXXXX, dado que era ella quien se encontraba adelantando en forma personal la apertura del expediente; sin embargo, al traspapelar el documento, que debía anexar al expediente físico, generó el que no se tuviese conocimiento del recurso impetrado por el usuario, habida cuenta que ni el Jefe del área ni la funcionaria del Archivo tuvieron acceso, durante la revisión del expediente aperturado al documento traspapelado, por lo que no fue posible efectuar el traslado para que el área competente, es decir la Oficina Jurídica para la resolución de la petición, dando lugar de esta forma a la configuración del silencio administrativo positivo, debido a que el recurso, al no llegar a la División de Gestión Jurídica de la Seccional, no fue resuelto dentro de los términos legales.

DE LA TIPICIDAD DISCIPLINARIA

Analizado el acervo probatorio obrante en el expediente, se encuentra probada la falta disciplinaria y la responsabilidad de la funcionaria investigada XXXXX XXXXX y se confirma el cargo endilgado en el escrito de acusación disciplinaria, teniendo en cuenta los elementos estructurales y descriptivos que conforman la falta disciplinaria de naturaleza gravísima descrita en el numeral 35 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que al tenor señala:

"Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

(...)

35. Dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo".

En el caso bajo estudio, nos encontramos frente a una falta disciplinaria de resultado, como lo es la ocurrencia del fenómeno jurídico del Silencio Administrativo Positivo, el cual constituye una sanción a la administración que opera en normas especiales, atribuibles a los funcionarios que intervinieron o tuvieron conocimiento del asunto, sea jurídico o secretarial, es decir, respecto de quien omitió hacer un trámite al que se encontraba obligado a realizar en atención a su cargo o de sus funciones.

Entonces, las palabras "dar lugar" descritas en el tipo disciplinario del Silencio Administrativo Positivo, permiten al operador disciplinario realizar una descripción amplia de la conducta que llevó como resultado a la ocurrencia de dicho fenómeno jurídico, que se presentó en el GIT de Secretaría de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, al no dar traslado al recurso de reconsideración interpuesto, al área encargada de resolverlo.

En este punto es importante mencionar que, generalmente el tipo disciplinario se caracteriza por ser un tipo abierto como quiera que debe efectuarse una remisión a otras normas del ordenamiento jurídico. En el caso que en particular analiza el Despacho, el silencio administrativo positivo que se advierte ha operado en la situación fáctica objeto de investigación, debe atenderse a lo que en la materia plantea el Estatuto Aduanero vigente para la época de los hechos investigados (Decreto 2685 de 1999).

Al respecto, se encuentra que la normatividad en comento, en su artículo 515 y siguientes, dispone que el término para resolver el recurso de reconsideración es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de su interposición y que su incumplimiento dará lugar al Silencio Administrativo Positivo, cuya consecuencia para la administración será, en los casos de mercancía aprehendida para definición de situación jurídica, la de hacer entrega de la misma al interesado previa presentación y aceptación de la declaración de legalización, cancelando los tributos aduaneros a que hubiere lugar y sin el pago de rescate.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

"Artículo 515.- Modificado. D. 1232/2001, art. 50. Recurso de reconsideración. Contra el acto administrativo que decida de fondo procede el recurso de reconsideración, el cual deberá interponerse dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación. El término para resolver el recurso de reconsideración será de tres (3) meses contados a partir de la fecha de su interposición".

"Artículo 519.- Modificado. D. 1198/2000, art. 23. Modificado. D. 4431/2004, art. 22. Incumplimiento de términos. Los términos para decidir de fondo previstos en el presente capítulo son perentorios y su incumplimiento dará lugar al silencio administrativo positivo... En los casos de mercancía aprehendida para definición de situación jurídica, dará lugar a la entrega de la misma al interesado previa presentación y aceptación de la declaración de legalización, cancelando los tributos aduaneros a que hubiere lugar y sin el pago de rescate".

Del material probatorio recaudado en la presente causa disciplinaria se encuentra probado que el Expediente DP 2016 2016 0000443 fue abierto el día 3 de febrero de 2016 por parte de la funcionaria investigada XXXXX XXXXX, del Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, como consecuencia de la aprehensión que hiciera la Policía Fiscal y Aduanera el día 30 de enero de 2016 mediante Acta No. 9000393 POLFA 0841 a la sociedad XXXXX XXXXX con NIT XXXXX.

De igual forma, se encuentra probado que la representante legal de la sociedad mencionada radicó ante el GIT de Documentación de la Dirección Seccional, recurso de reconsideración en contra de dicha aprehensión el día 3 de febrero de 2016 y que al día siguiente, es decir, el 4 de febrero de 2016, el mismo fue remitido al GIT de Secretaría de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera para su correspondiente reparto, el cual se efectuó por parte de la secretaria de tal grupo de trabajo, la funcionaria XXXXX XXXXX, a la investigada XXXXX XXXXX mediante planilla de reparto "Folio 22", dado que la misma se encontraba abriendo el expediente, según informó en diligencia de testimonio la primera de las mencionadas.

En el mismo sentido, el señor XXXXX XXXXX, Jefe de GIT de Secretaría en diligencia de testimonio indicó que este tipo de documentación, al llegar al grupo de trabajo, debía ser entregado a la persona encargada de abrir el expediente, para que ésta a su vez lo incorporara a la carpeta completa para poder ser remitido posteriormente a la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional, dependencia encargada de resolver el recurso; y que para la época de los hechos investigados era la funcionaria investigada, quien tenía esta función, esto es, aperturar el expediente y anexar los documentos que a ella le fueran entregados, referentes al mismo.

Así mismo, se encuentra probado que a dicho recurso no se le dio el respectivo traslado al área encargada de resolverlo dentro de los términos legales, pues como se evidencia a folio 82 del expediente, el mismo se surtió sólo hasta el día 22 de julio de 2016 mediante Planilla Múltiple de Remisión No. 599, donde se dejó constancia de la entrega extemporánea; lo anterior, como consecuencia del oficio de fecha 19 de julio de 2016, radicado por la representante legal de la empresa XXXXX XXXXX, quien solicitó la devolución del dinero al no habersele dado respuesta de la solicitud presentado el 3 de febrero del mismo año; momento en el cual se evidenció el error presentado, según el jefe del grupo interno de trabajo XXXXX XXXXX, al verificar que en el expediente físico archivado se encontraba incorporado el recurso sin que se le hubiese efectuado el trámite correspondiente para su resolución.

Finalmente, se encuentra probado que la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, luego de analizar la documentación presentada y verificar el tiempo transcurrido entre la fecha de radicación y la fecha en que se resolvió el recurso impetrado, al constatar que se encontraban vencidos los términos que la norma

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

establecía para su resolución, esto es, tres (3) meses contados a partir de su interposición, mediante Resolución No. 1-90-201-236-408-3171 del 22 de agosto de 2016, decretó el Silencio Administrativo Positivo respecto del recurso de reconsideración presentado por la representante legal de la sociedad XXXXX XXXXX el día 3 de febrero de 2016 y radicado con el número 1447, sobre la definición de la situación jurídica de la mercancía aprehendida por la Policía Fiscal y Aduanera el día 30 de enero de 2016.

Consecuente con lo expuesto, para este Despacho es dable concluir en grado de certeza que la investigada XXXXX XXXXX, con ocasión a las funciones que desempeñaba en el GIT de Secretaría de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, dio lugar a la configuración del Silencio Administrativo Positivo dentro del proceso DP 2016 2016 0000443, al no incorporar el documento que le fue entregado a través de planilla de reparto donde se describía como "OBJECCIÓN A ACTA DE APREHENSIÓN 9000393 POLFA 0841 DEL 30-01-2016", al expediente al cual hacía referencia el recurso interpuesto por la sociedad XXXXX XXXXX el día 3 de febrero de 2016, es decir, al expediente que se encontraba aperturando, para posteriormente ser entregado al área competente de resolverlo dentro de los términos legales, esto es, dentro de los tres (3) meses siguientes a su interposición de conformidad con el artículo 515 del Estatuto Aduanero.

Es importante precisar que, el mismo le fue entregado a través de la planilla antes mencionada pero no pudo ser trasladado gracias a que no se incorporó al expediente que se encontraba siendo aperturado por parte de la investigada.

Así las cosas, se encuentra que la conducta desplegada por la investigada constituye la falta disciplinaria descrita en el numeral 35 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, sin que exista duda alguna en relación a la concreción de la misma ni de la responsabilidad de la disciplinada en su comisión.

DE LA ILICITUD SUSTANCIAL

Verificada la existencia de la conducta realizada por la investigada XXXXX XXXXX y su tipicidad, se hace necesario examinar la ilicitud sustancial de la misma. En este punto es importante destacar que el ejercicio de la función pública y la condición de servidor del Estado, exige de éstos, actuación tanto pública como privada que acuse cabal respeto a la Constitución y a la Ley, lo cual implica acatamiento de deberes que trascienden el concepto de la función propiamente dicha, y llega hasta principios de naturaleza ética que deben animar el comportamiento público, que pasan por las nociones de probidad, transparencia, rectitud, entre otras, pero que dogmáticamente se conocen como "deberes funcionales", en tanto aparecen atados a la calidad de servidor público.

Así las cosas, debe ponerse de relieve que la oposición de la conducta observada por el funcionario público, frente al deber funcional impuesto, sin que concurra justificación que explique tal proceder, edifica el concepto de ilicitud sustancial.

En este sentido, la ilicitud sustancial hace alusión, a "la oposición de la conducta desplegada por el agente frente a los deberes funcionales exigibles, concebidos estos como el pilar de la salvaguarda de la función pública, en cuanto atenta contra el buen funcionamiento del Estado y el cumplimiento de sus fines, (...)A

De igual forma, resulta pertinente resaltar lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia C- 948 de 2002:

"Así mismo cabe concluir que la infracción disciplinaria siempre supone la existencia de un deber cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento genera la respuesta represiva del Estado y que dado que el propósito último del régimen disciplinario es la protección de la correcta marcha de la Administración pública, es necesario garantizar de manera efectiva la observancia juiciosa de los deberes de servicio asignados a los funcionarios del Estado

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

mediante la sanción de cualquier omisión o extralimitación en su cumplimiento, por lo que la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia pueden ser sancionados en este campo en cuanto impliquen la vulneración de los deberes funcionales de quienes cumplen funciones públicas".

Consecuente con lo expuesto, resulta dable señalar que, en el caso particular del Silencio Administrativo Positivo, el propósito es hacer efectivos los principios de celeridad, eficiencia y eficacia que rigen la actividad administrativa, mismos que se vieron socavados y que atribuye como contraria a derecho y susceptible de reproche disciplinario al dar lugar a la configuración del mismo.

Por lo tanto, en el caso bajo estudio, se logró demostrar que el Silencio Administrativo Positivo operó respecto del recurso de reconsideración impetrado el día 3 de febrero de 2016 y radicado bajo el No. 1447 por la representante legal de la sociedad XXXXX XXXXX, se dio como consecuencia de la omisión por parte de la funcionaria investigada al no incorporar para su posterior traslado por parte del funcionario competente al área competente, esto es, a la División de Gestión Jurídica para que ésta lo resolviera dentro de los términos legales, es decir, dentro de los tres (3) meses siguientes a su interposición, lo cual se evidencia que la misma, además de constituir la falta disciplinaria descrita en el numeral 35 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, inobservó los deberes funcionales insitos en los principios de celeridad, eficiencia y eficacia ya referidos.

Por estas razones se concluye que, la conducta de la investigada reviste de la ilicitud sustancial exigida en el artículo 5° de la norma mencionada, y así mismo, no se demostró que concurriera alguna de las causales descritas en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002 para justificar su omisión, afectando con ello las nociones de probidad, transparencia y rectitud que debe inspirar el ejercicio de la función pública.

DE LA CULPABILIDAD

Superado y verificado el análisis de tipicidad e ilicitud sustancial de la conducta que le fue endilgada a la funcionaria XXXXX XXXXX, este Despacho debe pronunciarse sobre la culpabilidad como elemento del tipo disciplinario. En ese orden, el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, establece que en materia disciplinaria las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa.

Sobre el particular la Corte Constitucional ha señalado que:

"Si la razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes, para que se configure violación por su incumplimiento, el servidor público infractor sólo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o culposamente, pues como ya se dijo, el principio de la culpabilidad tiene aplicación no sólo para las conductas de carácter delictivo sino también en las demás expresiones del derecho sancionatorio, entre ellas el derecho disciplinario de los servidores públicos, toda vez que "el derecho disciplinario es una modalidad de derecho sancionatorio, por lo cual los principios de derecho penal se aplican mutatis mutandi en este campo pues la particular consagración de garantías sustanciales y procesales a favor de la persona investigada se realiza en aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo en comento, y para controlar la potestad sancionadora del Estado"

Adicional a lo anterior, una particularidad que caracteriza al derecho disciplinario y que lo distingue de otros derechos represores, como el penal, es la posibilidad de que el operador, respecto de una misma falta y con base en los fundamentos probatorios existentes, pueda otorgarle a aquella el carácter de dolo o de culpa, dependiendo de las condiciones particulares en que fuera desarrollada la conducta investigada y de que la descripción del tipo disciplinario no contenga ingredientes normativos de carácter subjetivo que encuadren la conducta exclusivamente como dolosa. Este sistema denominado "numerus apertus" del derecho disciplinario lo distingue del "numerus clausus" del penal en

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

el que el legislador establece para cada conducta punible su forma de culpabilidad, particularmente cuando se trata de delitos que admiten la forma culposa.

En consecuencia, en el análisis del aspecto subjetivo, tratándose de la falta descrita en el numeral 35 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, es factible que la conducta de la investigada puede enmarcarse dentro de cualquiera de las dos concepciones o formas de responsabilidad previstas en el derecho disciplinario, es decir, que bien pudo haber incurrido en forma dolosa o en forma culposa en la generación del silencio administrativo positivo.

Para el caso que nos ocupa, se encuentra que la funcionaria investigada XXXXX XXXXX, al rendir versión libre y relatar lo ocurrido con el recurso de reconsideración sobre el cual se declaró el Silencio Administrativo Positivo objeto de la presente investigación, señaló que ella se había enterado de la situación presentada hasta el momento en el que su jefe le dijo que no se había contestado el recurso y se percataron de su error al verificar que efectivamente era ella quien lo había recibido, pero que no sabía cómo había llegado el recurso al expediente pues el mismo fue revisado por ella, por su jefe y la persona encargada del archivo de los expedientes, al momento de archivarlo, y frente al caso en particular, el recurso había aparecido incorporado en la carpeta de forma irregular.

De igual forma, indicó que de acuerdo al procedimiento interno de la entidad, el recurso debió ser enviado directamente por el GIT de Documentación Aduanera a la oficina de Jurídica y no a la División de Fiscalización, resaltando que en la misma acta de aprehensión dice que precede el recurso de reconsideración ante la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Medellín dentro de los 15 días siguientes a su notificación, ya que la División de Fiscalización Aduanera no era la competente para resolver recursos de reconsideración.

Que su función simplemente consistía en abrir los expediente con las actas de aprehensión de mercancía que llegaban allí, debía relacionar la documentación en el sistema CORAN y asignarle un funcionario para el trámite del proceso, para que finalmente el jefe asignara el expediente al funcionario encargado de tramitarlo, y en adelante ella no tenía andas que ver con el mismo.

Así las cosas, en su consideración, el documento nunca debió pasar por sus manos, pues el mismo debía llegar directamente a la Jurídica, independientemente de que el proceso hubiese sido asignado o no a un funcionario específico, resaltando que al llegar a su oficina ella no tenía por qué saber que se trataba de un recurso de reconsideración, más teniendo en cuenta que al leerlo en ninguna parte decía que se trataba de un recurso, y que en la planilla por medio de la cual se le hizo entrega del mismo tampoco decía eso, adicional a que ella no es abogada y que no tenía la función de examinar el contenido de los documentos que se le entregaban con el fin de resolverlos.

Adicionalmente, resaltó que sus funciones no eran desempeñadas solamente por ella, pues también se encontraba una practicante de la Universidad de Medellín con quien se distribuía la tarea de armar los expedientes y anexarles la documentación, por lo cual era posible que el mismo hubiese sido manipulado por la practicante, pues no se manejaba ningún tipo de control sobre los documentos que organizaba cada una.

Finalmente, la investigada aclaró que ella llevaba seis (6) en el cargo que se encontraba desempeñando para la fecha en que ocurrieron los hechos investigados; que ella recibió la debida inducción; que la practicante estuvo durante los 6 meses de práctica en el GIT de Secretaría; que su apoyo consistía en que se repartían el trabajo a realizar, que ella no recibió ninguna instrucción acerca del traslado que debía realizar del documento en mención; y que la persona encargada de trasladar el documento.

En consecuencia, en el análisis del aspecto subjetivo, tratándose de la falta descrita en el numeral 35 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, es factible señalar que la conducta de la

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

investigada puede enmarcarse dentro de cualquiera de las dos concepciones o formas de responsabilidad previstas en el derecho disciplinario, es decir, que bien pudo haber incurrido en forma dolosa o en forma culposa en la generación del silencio administrativo positivo.

Sin embargo, luego de adelantarse las etapas probatorias dentro de la presente causa disciplinaria, es dable concluir que en el caso sub examine, la configuración del Silencio Administrativo Positivo declarado mediante Resolución No. 1-90-201-236-408-3171 del 22 de agosto de 2016, obedeció a un descuido por parte de la funcionaria investigada XXXXX XXXXX, al no haber incorporado el recurso interpuesto dentro del Expediente No. DP 2016 2016 0000443 cuya apertura se estaba adelantando por ella en razón de sus funciones, y por ello no pudo darse el traslado correspondiente a la División de Gestión Jurídica para que allí se resolviera dentro del término legal, esto es, dentro de los tres (3) meses siguientes a su interposición; pues como ella misma lo indicó en versión libre, el documento debió traspapelarse debido al volumen de documentos que a diario ingresaban al Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de la División de Fiscalización de la Dirección Seccional Aduanera de Medellín, sin que este último planteamiento implique una causal de exoneración.

Consecuente con lo expuesto, para el Despacho es dable concluir que la inadecuada gestión de incorporación por parte de la funcionario investigada para que se diera el posterior traslado, operó como el factor determinante para que a la administración se le venciera el término legal que tenía resolver sobre el recurso de reconsideración presentado por la representante legal de la sociedad XXXXX XXXXX; gestión que no se realizó por la inobservancia del cuidado que la investigada debía tener respecto de la incorporación integral de los documentos que constituían el expediente que estaba abriendo, situación que se dio en el contexto de su ejercicio funcional como servidora adscrita al GIT de Secretaría de la División de Fiscalización encargada de abrir el respectivo expediente, dando en consecuencia lugar a la generación del Silencio Administrativo Positivo objeto de la presente causa disciplinaria.

DE LA CONTESTACIÓN A LOS ARGUMENTOS DE LA INVESTIGADA Y EL APODERADO

El Despacho no le asiste razón a la investigada y a su apoderado cuando pretenden señalar que el recurso de reconsideración sobre el cual operó el Silencio Administrativo Positivo, nunca debió llegar a sus manos, sino que el GIT de Documentación, debió clasificarlo y enviarlo a la oficina Jurídica pues era la competente para resolverlo, ya que de conformidad con lo manifestado bajo la gravedad del juramento por el jefe del GIT de Secretaria de la División de Fiscalización y la secretaria del mismo grupo de trabajo, el trámite interno es que el recurso debía remitirse a Fiscalización para que allí, una vez incorporado al expediente se diera el traslado a la oficina encargada de resolverlo.

Para el Despacho tampoco son de recibo los argumentos expuestos en relación a que la investigada XXXXX XXXXX, dentro de sus funciones delegadas no se encontraba la de adelantar las labores de mensajería interna respecto de la documentación que ingresara a tal dependencia, sino que la misma se limitaba a la apertura de expedientes con los documentos que se allegaban, y que tampoco estaba en sus funciones revisar el contenido de los mismos en aras de verificar si se trataba de un recurso o no, simplemente debía incorporar los documentos que le fueran entregados para que finalmente el jefe hiciera el reparto.

Lo anterior, por cuanto el objeto de reproche no se sustentó en que la investigada diera trámite al recurso como tal, es decir, que asegurara su resolución, sino en el cumplimiento de su función de incorporarlo al expediente que se encontraba aperturando, como quiera que apenas le había sido entregado para su conformación; pero ello no ocurrió debido a la inobservancia en sus funciones, pues contrario a garantizar la incorporación del mismo, lo traspapeló, situación que fue determinante para que la Administración como consecuencia de ese descuido, no hubiese resuelto dentro de los términos legales el recurso de

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

reconsideración interpuesto por el usuario aduanero, esto es, dentro de los tres meses que dispone el Estatuto Aduanero, dándose lugar con ello, a la configuración del silencio administrativo positivo.

Es de acotar que, este Despacho en ningún momento ha considerado que la investigada debía tener conocimiento sobre la naturaleza jurídica del documento, toda vez que su labor respecto del mismo, se centraba exclusivamente en su incorporación física al expediente, para que el funcionario competente, es decir, el jefe del grupo o la funcionaria de archivo lo remitiese al área que debía darle resolución. En el caso específico, ni el jefe de grupo ni la funcionaria de archivo tuvieron la oportunidad de analizar la procedencia de la remisión, toda vez que no tuvieron conocimiento del recurso gracias que no había sido incorporado físicamente por la investigada.

Finalmente, para el Despacho no puede recibir como excluyente de responsabilidad y menos como generador de duda que para que la época en que ocurrieron los hechos se encontrara una practicante ayudando en su gestión, pues de ninguna manera puede entenderse que la ayuda recibida la eximiera de sus deberes, pues como lo manifestaron cada uno de los testimonios aportados al plenario, era claro que la responsabilidad del practicante recaía en el funcionario, es decir, que si bien la practicante le prestaba una colaboración era a la investigada a quien correspondía garantizar el cumplimiento de sus funciones, que para el caso que nos ocupa, era el de incorporar el documento que le fue entregado , al expediente que se encontraba aperturando, independientemente de la naturaleza del mismo.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA

Conforme al artículo 42 de la Ley 734 de 2002, las faltas disciplinarias son gravísimas, graves y leves; las primeras se encuentran taxativamente descritas en el artículo 48 de la misma norma, mientras que las demás se estructuran por razón del incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución y la ley, siguiendo los lineamientos contemplados en el artículo 43 del Código Disciplinario Único para determinar la gravedad o levedad de la falta.

Así mismo, el numeral 9° del artículo 43 de la Ley 734 de 2002 señala que "La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave será considerada falta grave"; y el parágrafo del artículo 44 de la misma norma indica que: "La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones".

Consecuente con los parámetros legales planteados, este Despacho considera que la falta disciplinaria objeto de análisis en esta actuación, no obstante corresponder a una falta gravísima por el concepto taxativo, se ha de imputarse a la funcionaria XXXXX XXXXX a título de Culpa Grave, toda vez que los elementos de juicio incorporados en la actuación permiten evidenciar que en el particular se trató de una conducta caracterizada por la inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprimiría en sus actuaciones, la cual para el caso bajo estudio, se vio reflejado en el incumplimiento a la incorporación que ella debía realizar del documento mencionado al expediente que se encontraba aperturando para que posteriormente el mismo fuera trasladado al área correspondiente para su posterior resolución.

DE LA SANCION POR IMPONER

Dentro de la presente causa disciplinaria quedó demostrado que la funcionaria XXXXX XXXXX, quien para la época de los hechos prestaba sus servicios como funcionaria del grupo interno de trabajo de Secretaría de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, es responsable de cometer la falta

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

disciplinaria gravísima contenida en el numeral 35 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, consistente en dar lugar al silencio administrativo positivo.

Consecuentemente, configurados los presupuestos legales exigidos por el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, al obrar en el proceso prueba acerca de la certeza de la existencia de la falta y de la responsabilidad de la involucrada, es menester proceder a determinar la sanción a imponer, para lo cual se partirá de los siguientes presupuestos:

La conducta cometida por la disciplinada fue determinada como FALTA GRAVE, realizada a título de CULPA GRAVE, cuya sanción se encuentra establecida en el artículo 44 del Código Disciplinario Único, de la siguiente manera:

"Artículo 44. Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:

5. Suspensión, para las faltas graves culposas. (...)"

Respecto al término de la suspensión, el artículo 46 de la Ley 734 de 2002 establece que debe graduarse dentro de unos rangos preestablecidos de la siguiente manera:

"Artículo 46. Límite de las sanciones.

La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. (...)

Aclarado lo anterior, al tenor del artículo 47 de la ley disciplinaria que fija los criterios a tener en cuenta para determinar el término de duración de la suspensión, este Despacho encuentra necesario tener en cuenta que la funcionaria procesada no ha sido sancionada, fiscal ni disciplinariamente, de conformidad con la consulta realizada a través de las página web de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación, como consta a folio 118 del expediente disciplinario, y que, al momento de la comisión de la falta, no pertenecía al nivel directivo o ejecutivo de la entidad, así que, a pesar de lo reprochable de su conducta, no se afectaron derechos fundamentales.

Teniendo en cuenta lo anterior, en ejercicio del principio de la proporcionalidad, debe imponerse a la disciplinada XXXXX XXXXX, la sanción disciplinaria mínima para este tipo de casos, consistente en la SUSPENSIÓN para el ejercicio de su cargo por el término de UN (1) mes, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive del presente proveído.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de XXXXX XXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía No. XXXXX de XXXXX (XXXXX), por la conducta consignada como cargo en el Auto No. 17412-00001 del 23 de febrero de 2017; actuar constitutivo de falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 734 de 2002.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, IMPONER a XXXXX XXXXX, sanción disciplinaria consistente en la SUSPENSIÓN para el ejercicio de su cargo por el término de UN (1) mes, teniendo en cuenta que la conducta fue calificada como grave a título de culpa.

TERCERO: NOTIFICAR EN ESTRADOS la presente decisión a la investigada XXXXX XXXXX y a su apoderado, el Doctor XXXXX XXXXX, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 734 de 2002.

CUARTO: ADVERTIR que contra la presente decisión procede el RECURSO DE APELACIÓN.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-00-2016-187

QUINTO: En firme la presente decisión, COMUNICARLA en la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el artículo 174 del Código Disciplinario Único.

SEXTO: REMITIR copia de la presente decisión al nominador de la procesada para que proceda a ejecutar la sanción impuesta, de conformidad con lo establecido en el numeral 3° y párrafo del artículo 172 de la Ley 734 de 2002.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE,



JORGE ADRIANO MORENO PONCE
Subdirector de Investigaciones Disciplinarias
UAE Agencia ITRC